

1500054-94.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... e que já possui um processo por tráfico, mas saiu na audiência de custódia (fls. 199).

Claudemir Tenório da Silva, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido pela incidência de tráfico. Contou que passaram perto de um bar, que estava fechado, e viram que havia usuários aguardando a chegada da droga. Encostaram a viatura e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500054-94.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-94.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2009996/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 22395043 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 68/22/608 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2009996 - DEL.POL.SALTO, 68/22/608 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GABRIEL DA SILVEIRA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

CHARLES JESUS DA ROCHA e FELIPE GABRIEL DA SILVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), também do Código Penal, porque, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta de 22h08min, na avenida Marília, altura do nº 143, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de propósitos entre eles, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 5 (cinco) porções de "cocaína", com peso bruto aproximado de 3,3g (três gramas e trinta centigramas), e 12 (doze) porções de cocaína, em sua forma petrificada,

popularmente conhecida como "crack", com peso bruto aproximado de 5,9g (cinco gramas e noventa centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 17 de março de 2022 (fls. 126/128) e os réus foram citados (fls. 187/190).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum e os réus foram interrogados ao final (fls. 196/199).

Em memoriais, o Dr. Promotor requereu a procedência da ação e a condenação dos acusados, com fixação das penas-bases dos acusados acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da denúncia, além da reincidência com relação ao réu Charles, entendendo não ser possível a benesse do artigo 33, §4º da Lei em comento. Ao final, pugnou pela imposição, para ambos os acusados, de regime fechado para início do cumprimento das penas privativas de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 206/216). A Defesa do réu Felipe requereu sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) ou, alternativamente, em caso de condenação pelo tráfico, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, com substituição por restritivas de direitos (fls. 217/219). A Defesa do réu Charles, por sua vez, requereu sua absolvição e, subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, imposição de regime aberto para início do cumprimento de pena, com substituição por restritivas de direitos e o direito de aguardar o julgamento do feito em liberdade. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) (fls. 220/229). É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 2/4), autos de exibição/apreensão (fls. 11) e de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 13), e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/88), além da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

O réu Charles, em sede policial, negou o crime, disse que, malgrado fosse usuário de drogas, não trazia nenhum entorpecente ou dinheiro consigo, tampouco viu a apreensão da droga, e também negou conhecer o corréu Felipe (fls. 12). Em juízo, tornou a negar o crime, dizendo que não tinha dinheiro com ele e que não conhece o réu Felipe. Disse que vinha andando, quando foi parado por um motoqueiro desconhecido, que lhe perguntou "dos moleques". Afirmou ser usuário de drogas, por isso tinha dois gramas de crack em seu bolso, e havia entrado no mato para usar. Contou que havia comprado o crack no bairro São Pedro São Paulo. Relatou que mora na rua Monteiro Lobato e trabalhava como autônomo, de servente, no bairro Estação, já teve passagens anteriores, por "assalto" e tráfico. Por fim, disse que o Felipe não estava perto dele, quando foi abordado (fls. 199).

O réu Felipe, em sede policial, disse que estava passando pela avenida Marília, quando foi abordado por um motociclista, que lhe disse "está sumido", ao que respondeu "eu não, você é que esta sumido" e, em seguida foi a um bar e comprou uma garrafinha de cerveja. Enquanto estava no bar, foi abordado pelos guardas municipais, que encontraram um tubinho amarelo, contendo cocaína até a metade, e mais R\$72,00 (setenta e dois reais) em espécie, fruto de seu trabalho. Neste momento, foi algemado e conduzido à Delegacia. Admitiu ser usuário de cocaína e negou ter corrido com a chegada dos guardas municipais ou que estivesse realizando tráfico de drogas no local (fls. 14). Em juízo, disse que tinha ido encontrar com uns colegas, no caminho encontrou o rapaz de moto, cujo nome não conseguiu se lembrar, e parou para conversar com ele. Relatou que, após conversarem, seguiu seu caminho, quando as viaturas passaram por ele, e ele entrou no bar e foi retirado de lá pelo guarda. Declarou que só havia um pino pela metade e R\$72,00 (setenta e dois reais) consigo. Disse não ter visto a prisão de Charles, que foi trazido de dentro do mato, enquanto ele já estava na viatura. Contou que estava desempregado e só

fazia bicos nos finais de semana, com balonismo. Disse ser usuário de cocaína e maconha, e que já possui um processo por tráfico, mas saiu na audiência de custódia (fls. 199).

Claudemir Tenório da Silva, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido pela incidência de tráfico. Contou que passaram perto de um bar, que estava fechado, e viram que havia usuários aguardando a chegada da droga. Encostaram a viatura e decidiram ir a pé, observar os usuários, e ficaram numa praça próxima, pouco iluminada, e chamaram outra viatura. Notaram a chegada de dois rapazes que foram abordados por um motoqueiro, que lhes disse que queria cocaína, e queria da branca, e entregou o dinheiro para o Felipe. Felipe disse ao Charles para ir buscar a droga em terreno próximo. Quando a outra viatura chegou na avenida, o Felipe gritou para o Charles, que havia sujado. A testemunha contou que foi ao encalço do Charles, que dispensou uma sacola, e seu parceiro foi atrás do Felipe, com quem se achou uma porção de droga, um pino de cocaína, e uma quantia em dinheiro. O motoqueiro fugiu do local. Abordado o Charles, no terreno que corta outra rua, o primeiro caiu ao chão. A sacola que ele havia dispensado continha 12 porções de crack e 04 de cocaína. Charles negou a traficância e disse que o motoqueiro apenas havia pedido informações, e não, droga. Contou que seus colegas de farda já haviam prendido o Felipe por tráfico. Ao ser questionado sobre a distância e sobre a possibilidade de não ter entendido tudo o que havia sido dito pelos réus, disse que estavam a cerca de 10 metros dos réus, quando eles negociaram a venda com o motoqueiro, e que foi possível ver e ouvir com clareza o que todos diziam (fls. 198).

Ronaldo Siqueira de Melo, guarda municipal, prestou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda, acrescentando que, depois da prisão de Felipe, conversando com o último, lembrou-se de que já havia participado de uma prisão anterior do réu, também por tráfico. Reafirmou que estavam a cerca de 10 metros dos réus, quando eles negociaram a venda com o motoqueiro, e puderam ver e ouvir bem o que todos diziam (fls. 198).

Encerrada a instrução, restou comprovada a prática do tráfico de drogas por ambos os acusados, na forma descrita na denúncia.

De fato, como bem mencionado pela Acusação, as versões dos réus se mostraram isoladas do restante do conjunto probatório. Ademais, possuem incongruências entre si e entre o que cada um deles disse na Delegacia e em juízo.

Felipe, desempregado, disse que trazia droga e dinheiro consigo, mas eram fruto de seu trabalho. Afirmou que foi encontrar uns colegas e, no caminho, parou para conversar com o rapaz de moto, que era seu conhecido, mas cujo nome não soube dizer. Na sequência, viu a viatura, mas não correu, apenas entrou no bar para comprar uma garrafinha de cerveja, e de lá foi retirado pelos guardas. Disse que não conhecia Charles.

Note-se que Felipe não arrolou qualquer dos colegas como testemunhas, não demonstrou que realizasse os "bicos" de finais de semana, e que surgiram apenas no momento do interrogatório em juízo e sequer se lembrou do nome do colega motoqueiro, com quem havia acabado de conversar, ou seja, não trouxe qualquer elemento capaz de comprovar sua versão ou que se mostrasse suficiente, para desconstituir o que foi dito pelos guardas municipais.

Já o réu Charles, na Delegacia, negou que trouxesse drogas consigo, mas em juízo, admitiu que trazia 02 gramas de crack, fato curioso, porquanto tal droga sequer foi mencionada inclusive pelos guardas municipais, que disseram ter encontrado 12 porções de crack e 04 de cocaína na sacolinha dispensada por ele, além de 01 microtubo de cocaína com Felipe, não se tendo notícias de apreensão destes dois gramas de cocaína, que também não fazem parte da denúncia. Ao mesmo tempo, ainda na Delegacia, quando negou possuir drogas consigo, Charles justificou sua presença no interior da mata para usar as drogas que haveria comprado.

Ademais, Charles não trouxe qualquer justificativa para estar no local dos fatos, região que fica bastante distante de sua residência, próxima ao Centro da cidade, na rua Monteiro Lobato, e também do bairro em que alegou ter comprado a droga, Terras de São Pedro e São Paulo, parecendo incongruente que estivesse tão afastado de ambos estes locais, apenas para usar a droga que informou possuir.

Por outro lado, os depoimentos dos guardas municipais foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar qualquer um dos acusados.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do crime, por ambos os acusados, na forma mencionada na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste

sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

O pedido das Defesas de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 11 de janeiro de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado a saciedade que os réus praticaram o crime que lhes foi atribuído na denúncia, sendo incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), também do Código Penal, porque, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta de 22h08min, na avenida Marília, altura do nº 143, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de propósitos entre eles, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 5 (cinco) porções de "cocaína", com peso bruto aproximado de 3,3g (três gramas e trinta centigramas), e 12 (doze) porções de cocaína, em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com peso bruto aproximado de 5,9g (cinco gramas e noventa centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma incontestada, a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta dos acusados, razão pela qual, passo a lhes aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Com relação ao réu Charles:

Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, verifico a presença de elemento que enseja a majoração da pena-base do acusado nesta fase, pois ele ostenta maus antecedentes, já que foi condenado anteriormente, de forma definitiva, no processo de nº 0004733-95.2014.8.26.0526 (fls. 48), pois já decorrido o prazo depurador de 05 anos entre a extinção da pena e o cometimento do crime pelo que é ora julgado.

Assim, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 550 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Como acima mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública.

Incide, ainda, a agravante do artigo 61, inciso, I, do Código Penal, já que Charles é reincidente (autos nº 0006401-33.2016.8.26.0526 - fls. 49).

Ante a presença de duas agravantes, aumento sua pena para 06 anos e 06 meses de

reclusão, além de 650 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Não há causas de aumento de pena e a reincidência do réu impede a aplicação do redutor no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Torno a pena definitiva, à míngua de outras causas modificadoras e fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em lei.

Com relação ao réu Felipe:

Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, verifico a presença de elemento que enseja a majoração da pena-base do acusado nesta fase, pois ele possui culpabilidade acentuada, porquanto está sendo processado, também por tráfico de entorpecentes, e estava em gozo do benefício de liberdade provisória, concedida nos autos de nº 0000781-

64.2021.8.26.0526 (fls. 44), quando praticou o crime, pelo que é ora julgado.

Assim, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 550 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Como acima mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública, razão pela qual aumento sua pena para 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Não há causas de aumento de pena e, malgrado não possua antecedentes criminais, excetuado o processo de nº 0000781-64.2021.8.26.0526 (fls. 44), pelo que ainda não foi julgado, e mantenha sua condição de primariedade, é certo que, colocado em liberdade por delito idêntico (fls. 44), não hesitou em se envolver novamente com a vida criminosa, voltando, ao que tudo indica ao comércio de substâncias ilícitas, até ser detido mais uma vez. Assim, evidenciou-se que não se conscientizou da gravidade de seus atos, não mudou suas metas de vida, nem valorizou a oportunidade de se reencaminhar que lhe foi dada, mostrando que se mantido solto, não irá interromper sua prática criminosa, razões todas pelas quais, entendo inviável a aplicação do § 4º. do art. 33, da lei em tela, pois comprovada sua dedicação à atividade criminosa.

Torno a pena definitiva, à míngua de outras causas modificadoras e fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em lei.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para: 1) CONDENAR o réu CHARLES JESUS DA ROCHA, qualificado nos autos, RG 41.277.858, CPF

346.466.358-28, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), também do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 650 dias-multa, com unidade no mínimo legal; e 2) CONDENAR o réu FELIPE GABRIEL DA SILVEIRA, qualificado nos autos, RG 45.325.727, CPF 465.225.188-21, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), também do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 600 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, Charles é reincidente, e a vedação contida no inciso II do artigo

44, do Código Penal é expressa quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, em razão da pena aplicada, o acusado também não preenche os requisitos do inciso I do mesmo artigo, malgrado não se trate de crime cometido com violência. No tocante ao réu Felipe, nos termos do inciso II do referido artigo 44, do Código Penal, as circunstâncias do crime demonstram que a substituição por penas restritivas de direitos não se mostra suficiente para a reeducação do acusado, porquanto estava em liberdade provisória por crime de tráfico, referente aos autos de nº 0000781-64.2021.8.26.0526 (fls. 44), quando praticou o crime narrado na inicial deste feito. Assim, malgrado pudesse preencher, em tese, os requisitos indicados nos incisos I e II, suas condições pessoais indicam que também não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O regime de cumprimento de pena, para ambos os réus, deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo da conduta dos réus, e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Determino, ainda, que os réus não poderão recorrer desta sentença em liberdade, considerando que suas custódias foram determinadas durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foram inicialmente determinadas. Também porque Charles é reincidente específico, além de possuir outra condenação já atingida pelo prazo de cinco anos entre a extinção da pena e o cometimento do crime aqui julgado. Felipe, por sua vez, já respondia por outro feito relativo a tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, quando foi preso cometendo o crime pelo qual foi agora condenado.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Acrescente-se a isso que o réu é reincidente (ostenta condenação anterior com trânsito em julgado por violação de direito autoral (fls. 176/177), a evidenciar que faz do crime meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a justificar o tratamento mais severo. Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/500000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observo não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, conforme deliberação na sessão virtual de 20 a 27 de agosto p.p., item "a", onde foi determinada "reavaliação das prisões preventiva de pais e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes fixadas pela Segunda Turma", pois inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem que os réus se encontrem na situação ali prevista.

Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a

redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Recomendem-se os réus onde se encontram presos.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/2006) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA